

1518699-62.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... comprar drogas e negou a prática do tráfico (fl. 12).

De acordo com a denúncia, as circunstâncias que envolveram os fatos, tendo os denunciados sido abordados em atitude suspeita e tentado fugir da abordagem policial, revelam que eles praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes. Comprova isso, ainda, o fato de terem sido encontradas, com os denunciados, porções de drogas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1518699-62.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518699-62.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219732/2020 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 13408068 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 7310/20/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2219732 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO LOPES SARAGOÇA e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

DIOGO LOPES SARAGOÇA e GLEIDSON CONCEIÇÃO NEVES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 cc. os artigos 29 e 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 4 de setembro de 2020, por volta das 22h30, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19 (Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020), na Rua do Cromatismo, 10, viela Botucatu, Jardim Ângela,

nesta cidade e comarca da Capital, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, traziam consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 119 porções de tetrahidrocannabinol (292,3 gramas), 50 porções de cocaína na forma de crack (5,6 gramas), 152 porções de cocaína (58,9 gramas) e 3 frascos contendo "lança-perfume" (13 mililitros), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 59,00 (cinquenta e nove reais) em espécie e um caderno contendo anotações da contabilidade do tráfico, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 13/16, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 31/32 e Laudo de Constatação de fls. 33/36.

De acordo com a denúncia, segundo restou apurado, policiais militares, em patrulhamento, avistaram os denunciados correndo no sentido de uma viela e decidiram pela abordagem. Naquele momento, os denunciados tentaram fugir, mas foram detidos em seguida. Em revista pessoal, foi localizada, com DIOGO, uma sacola plástica contendo maconha, cocaína, crack e lança-perfume, além de R\$ 28,00 (vinte e oito reais) em espécie; e, com GLEIDSON, foi localizada uma mochila, em cujo interior havia um tablete pequeno de maconha, R\$ 31,00 (trinta e um reais) em espécie e um crachá com nome de Jailson, mas contendo a foto do denunciado. Narra a denúncia que, na ocasião, foi abordado, também, Eric Tadeu Neves da Silva, com dois frascos de lança-perfume e um pino de cocaína, o qual foi autuado como incurso no artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda, os policiais, em incursão na viela, localizaram, sob o beiral de uma residência, a cerca de dois metros de onde os denunciados foram abordados, uma bolsa preta e uma bolsa vermelha, em cujo interior havia maconha embalada com o mesmo invólucro que envolvia o tablete encontrado com GLEIDSON, e dois papéis com letras e números. Segundo a exordial acusatória, indagado, DIOGO informou que havia acabado de vender para Eric dois lança-perfumes, o que foi confirmado por esse. Por sua vez, GLEIDSON, ao ser questionado, apresentou diferentes versões sobre o que estava fazendo no local. Ambos negaram a propriedade das duas bolsas por último referidas.

Interrogado em solo policial, DIOGO confessou que vendia drogas no local, assumiu a propriedade das drogas encontradas na sacola, mas negou que os entorpecentes encontrados nas bolsas lhe pertencessem (fl. 11).

GLEIDSON, por sua vez, alegou que se encontrava no local para comprar drogas e negou a prática do tráfico (fl. 12).

De acordo com a denúncia, as circunstâncias que envolveram os fatos, tendo os denunciados sido abordados em atitude suspeita e tentado fugir da abordagem policial, revelam que eles praticavam o tráfico ilícito de entorpecentes. Comprova isso, ainda, o fato de terem sido encontradas, com os denunciados, porções de drogas individualmente embaladas, prontas para a venda. Verifica-se, ademais, que os denunciados praticaram o crime se aproveitando da situação de estado de calamidade pública, decretada nas esferas Federal, Estadual e Municipal, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus.

Por decisão datada de 5 de setembro de 2020, a prisão em flagrante dos indiciados foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (fls. 74/76).

Foi impetrado Habeas Corpus, tendo sido concedida a ordem a fim de revogar as prisões preventivas dos acusados (fls. 195/202).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 07 de outubro de 2020 (fls. 203/204). Os Réus foram citados (fls. 223 e 224).

As Defesas constituídas pelos acusados apresentaram Resposta à Acusação (fls. 233/235 e 261).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 262/263).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas Policiais Militares e os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates orais. O Ministério Público requereu, em suma, a procedência parcial da ação penal. Sustentou que com relação ao Réu Diogo há provas da prática do crime de tráfico de drogas, requerendo a sua condenação, com aplicação do redutor, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Com

relação ao Réu Gleidson requereu a absolvição.

A Defesa do Réu DIOGO, a seu turno, reiterou o pedido formulado pelo Ministério Público, com a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa do Réu GLEIDSON, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do Réu. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A peça acusatória está amparada pela prova da materialidade – Auto de Exibição e Apreensão (fls. 31/32), Laudos Periciais (fls. 33/36 e 258/260), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria do Réu DIOGO no cometimento do crime de tráfico de drogas também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Todavia, com relação ao acusado GLEIDSON a prova produzida não foi capaz de demonstrar efetivo envolvimento do réu com o narcotráfico, pelo que a desclassificação para a infração de porte de droga para consumo pessoal se mostra, realmente, de rigor.

De imediato, importante salientar que a absolvição do réu GLEIDSON se apresenta impossível, isso porque há indícios veementes do envolvimento dele com drogas, tanto que os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que com Gleidson encontraram substância entorpecente (um tablete/porção de maconha).

Por outro lado, o réu GLEIDSON possuía pouca quantidade de droga e declinou nas duas oportunidades em que foi ouvido, ou seja, na fase policial e em juízo, que estava no local para comprar entorpecente.

Com efeito, extrai-se do interrogatório do Réu Gleidson colhido a fl. 12 que:

“Informa que realmente passou para comprar entorpecente, foi quando viu toda ação policial, resolveu correr porque temeu sofrer uma represália por parte dos Pms. Que nunca passou por aquilo. Que desconhece o Diogo e o outro rapaz, que as drogas encontradas não são suas até porque não meche com tráfico. Que sua família foi cientificada”.

Em sendo assim, devido a fragilidade da prova colhida no curso da instrução a confirmar que o réu GLEIDSON promovia o tráfico de drogas, deve ser operada a desclassificação.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha policial militar Isac Grigorio da Costa narrou, em síntese, que não se recorda bem, lembra que adentraram o local, conhecido como ponto de tráfico de drogas, adentraram a viela quando de repente veio um rapaz moreno correndo na direção dos policiais (Réu Gleidson) e o outro rapaz correu em outra direção (Réu Diogo). Em posse de Diogo tinha pouca droga e ele assumiu o tráfico de drogas ali. Diogo aparentava estar sob efeito de droga ou álcool. Procuraram no local se existia mais porções de droga e conseguiram achar uma pochete com certa quantidade de drogas que foi apresentada no DP. O parceiro deteve o acusado Gleidson. Lembra que com Gleidson, rapaz mais alto, foi encontrado um tablete de mais ou menos cinco, dez gramas de maconha. Não se recorda se as drogas encontradas no local eram semelhantes com aquelas encontradas com os réus. Gleidson também tinha dichavador e papel para fazer uso da maconha. Gleidson falou que estava indo comprar. Lembra que tinha um terceiro indivíduo (ERIC) que informou que tinha ido comprar.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Everton Henrique da Silva Oliveira, que narrou, em suma, que estava em patrulhamento e decidiram fazer incursão no local. Localizaram três indivíduos. Não sabe precisar a quantidade que foi encontrada com cada um. Gleidson tinha uma porção de maconha. Foi localizada um bolsa com drogas no beiral no interior da viela. Não se recorda a quantidade e quais eram os tipos. Recorda-se que um deles apontou o outro como vendedor. Ninguém assumiu a droga apreendida no beiral. Não se recorda se Diogo confessou no local. Não se recorda se Diogo aparentava estar em condições normais. Gleidson foi posteriormente até a Base pedir desculpa e conversar com a equipe. Diogo não se recorda se tinha droga com ele na ocasião.

A testemunha arrolada pela Defesa do Réu Gleidson, Gabriel Jesus Gomes, narrou, em síntese, que conhece o réu e trabalha com ele há dois anos. O réu trabalhou com o depoente no dia do ocorrido até por volta de 22:00 horas. No outro dia o réu não compareceu, achou estranho e foi atrás da irmã dele. O réu continua trabalhando com o depoente. Não tem conhecimento do crachá.

Ao ser interrogado em juízo, o réu DIOGO confessou a prática delitiva, extraíndo-se de seu interrogatório que está com 20 anos de idade. Está trabalhando de ajudante de pedreiro. Parou de estudar na oitava série. Mora com a mãe e a irmã. Estava sim traficando no dia. Estava sob o efeito de droga. Gleidson e Eric eram compradores. Admite que tinha as drogas encontradas na sacola que possuía para vender, mas drogas encontradas em outro local não eram do interrogando.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Ao ser interrogado em juízo o Réu GLEIDSON negou a prática do crime de tráfico de drogas e narrou, em síntese, que está com 40 anos de idade. Está trabalhando cortando cabelo. Estudou até o segundo grau completo. Mora atualmente com a irmã. Desde a infância teve instrução que não dava chance para se envolver, porém, infelizmente, naquele momento, correu pelo susto que tomou. Nunca passou pela sua história situação do tipo. Tinha comprado um pedaço de maconha.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que as ilustres Defesas não apresentaram nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar os acusados, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu DIOGO trazia consigo a droga que foi apreendida, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, em relação ao Réu DIOGO inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

A finalidade de narcotraficância, em relação ao Réu DIOGO foi evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela considerável quantidade de droga apreendida, incompatível com a condição de mero usuário; b) pelas circunstâncias da prisão; c) pelos depoimentos das testemunhas e confissão do acusado. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu DIOGO trazia consigo as drogas que foram apreendidas com ele para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, com relação ao Réu DIOGO

inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Sendo, pois, indubitável a autoria e a destinação da droga, a condenação do Réu DIOGO por crime de tráfico se impõe.

Com relação ao Réu GLEIDSON, como o porte de entorpecentes pelo acusado ficou bem demonstrado e como a materialidade delitiva restou igualmente evidenciada, melhor será, por aqui, sejam os fatos desclassificados para porte de entorpecente para uso próprio, eis que bastante frágil, insista-se, a acusação de tráfico de drogas.

Deve ser afastada a agravante de terem os agentes cometido o crime em ocasião de calamidade pública, conforme artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Com efeito, em que pese o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia em razão do coronavírus (COVI-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos." (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021). (grifos nossos).

No mesmo sentido: Apelação Criminal nº 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021; Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021 e Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021.

Reconhecida a ocorrência do delito de tráfico e a responsabilidade do acusado DIOGO, passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, conforme se infere da Certidão a fl. 286. A culpabilidade não ultrapassa o normal desvalor da conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o valor unitário no menor patamar.

Na segunda fase, reconheço as circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário, bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do "caput" do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de dois terços, chegando ao resultado de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº

118.533).

No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu é primário, sem antecedentes desabonadores e realizou tráfico sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos).

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos).

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

RÉU GLEIDSON

Trata-se de acusado primário e sem qualquer antecedente desabonador, conforme certidão a fl. 283. Assim, aplico a advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I, Lei 11.343/06).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, para (1) CONDENAR o acusado DIOGO LOPES SARAGOCA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, impondo a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo e, (2) em relação ao Réu GLEIDSON CONCEICAO NEVES DESCLASSIFICAR o crime descrito na denúncia para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 e CONDENAR o acusado GLEIDSON CONCEICAO NEVES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, impondo, em consequência, advertência sobre os efeitos das drogas (art. 28, I, Lei 11.343/06). A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu Diogo tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, deve ser facultado ao réu Diogo o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003,

condeno cada réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.
Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados".
P.I.C.
São Paulo, 01 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA